

1500382-02.2022.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Réu conhecido dos meios policiais pelo tráfico, ele não exerce ocupação lícita, não aparentava estar sob efeito de entorpecente e ele contou, no momento da prisão, que a droga era destinada ao tráfico, sendo que um dia iria sair. Em linhas gerais esse foi o teor do depoimento do policial militar Bruno.

De mais a mais, reforçando o quanto relatado pelos policiais, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500382-02.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500382-02.2022.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DOS SANTOS ALTÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. LEONARDO DOS SANTOS ALTÃO, qualificado nos autos a fls. 13, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 28 de abril de 2022, por volta das 20h30min, na Avenida 11-A nº 73, Bairro Vivendas

do Bom Jardim, nesta cidade e Comarca, teria trazido, com finalidade comercial, 12 (doze) porções de maconha, bem como teria em depósito, com o mesmo escopo, outras 21 (vinte e uma) porções do mesmo entorpecente, totalizando o peso líquido de 34,320 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que "policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Vivendas quando avistaram o denunciado saindo de sua residência, situada à Avenida 11-A, nº 73.

Em razão de ser LEONARDO pessoa conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas, os policiais citados decidiram abordá-lo, quando encontraram com ele doze porções de 'maconha', a quantia de cento e noventa e dois reais, em notas diversas, e um telefone celular.

Irene dos Santos Altão de Carvalho, avó do denunciado, autorizou a realização de vistoria na residência por parte dos agentes públicos, os quais encontraram, no quarto de LEONARDO, sobre o guarda-roupas, outras vinte e uma porções de 'maconha', e, em um quarto de despensa, localizado aos fundos do imóvel, uma balança e uma faca com vestígios de 'maconha'.

No local, o denunciado admitiu para os policiais militares a propriedade das drogas e a prática do tráfico de entorpecentes."

A denúncia de fls. 65/67 foi recebida em 27 de maio de 2022 (fls. 69). O Réu foi devidamente citado (fls. 100) e apresentou defesa preliminar em fls. 90/92, rejeitada a fls. 93/95. Na instrução da foi colhida prova oral e, ao final, o Réu foi interrogado (cf. fls. 184).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia (fls. 182/183).

A douta Defesa, por seu turno, a fls. 185/189, afirmou que não existe prova apta a impor o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que com o Réu seria usuário de drogas, pugnando pela absolvição e, não sendo o caso, requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no mais, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

Ao término da instrução processual e após uma atenta análise dos autos, é de se afirmar que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está evidenciada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/05, boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 10, pelo auto de constatação de fls. 24/26, na guia de depósito de fls. 54, no laudo de exame químico-toxicológico em fls. 144/145, laudo pericial de fls. 116/143, bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal.

A autoria é certa contra o Réu que, na fase inquisitorial optou pelo silêncio (fls. 04), ao passo que em Juízo sustentou que saia de casa com um amigo quando foi abordado por policiais, os quais encontraram doze porções de droga, que iria fumar, de forma que foram até sua residência e localizaram o restante do entorpecente, nada disso, contudo, destinado ao tráfico, porque destinado ao seu consumo. Ademais, não falou aos policiais que o entorpecente seria traficado, nada falou na delegacia, trabalha com um tio e é usuário de drogas.

De início deve ser destacado que, como se sabe, o direito ao silêncio é cláusula constitucionalmente assegurada, mas não é crível se acreditar que aquele que tenha

sido injustamente preso pela prática de um crime assemelhado ao hediondo tivesse a frieza de manter-se calado para somente em Juízo informar a prisão equivocada, demonstrando que o Réu nada tinha a indicar em sua defesa no momento de sua prisão, cabendo salientar brilhante excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, pois ele “assumiu comprometedor, ainda que legalmente tolerada, postura silente, quando é certo que aquele que se vê injustamente acusado, trata, logo, de anunciar a injustiça da acusação, se convidado a falar sobre ela” (TJSP, Ap. 990.09.059887-5, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 04.08.2009).

Sua versão não se sustenta e, fosse verdadeira, teria feito prova nesse sentido, em especial ouvindo sua avó e o mencionado amigo, ônus que lhe competia, com base no artigo 156 do Código de Processo Penal.

O policial militar Deivid, na fase judicial, confirmou que estavam em patrulhamento porque o local é conhecido ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram o Réu saindo de sua residência e, abordado, encontraram com ele doze porções de maconha embaladas em saquinhos de sacolé, dinheiro e celular. Diante disso, com autorização da avó e do tio do Acusado, que não concordam com seu modo de vida, vistoriaram a casa e encontraram o restante do entorpecente, além de uma faca e uma balança de precisão. Ademais, é o Réu conhecido dos meios policiais pelo tráfico, ele não exerce ocupação lícita, não aparentava estar sob efeito de entorpecente e ele contou, no momento da prisão, que a droga era destinada ao tráfico, sendo que um dia iria sair. Em linhas gerais esse foi o teor do depoimento do policial militar Bruno.

De mais a mais, reforçando o quanto relatado pelos policiais, o telefone celular apreendido com o Réu (fls. 10), por autorização judicial (fls. 36) foi submetido à perícia, cujo laudo foi encartado em fls. 116/143 e demonstra claramente que o Acusado transacionava maconha (cf. fls. 132/135 e 138/141).

A análise das provas indica que o Acusado, ao contrário do que sustenta a douta Defesa, infringiu o disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343, de 23.06.2006. Isso se deve porque o Réu trazia consigo e tinha em depósito consideráveis porções de maconha, o que, aliado à forma em que estava acondicionada, o conhecimento que os policiais tinham de sua vinculação ao tráfico e sua própria confissão aos militares, confirmam o exposto na denúncia, não podendo se ignorar que o Réu não estava sob efeito de drogas e, ademais, o laudo pericial de fls. 116/143, realizado no aparelho de telefone celular consigo apreendido deu mostra clara de sua traficância.

Nem mesmo se olvide afirmar de que o Réu seria usuário de entorpecente e a droga seria para o próprio consumo, diante dos fatos acima destacados, que apontam o narcotráfico, convindo ressaltar, inclusive, que sequer há prova de que o Réu fosse consumidor de entorpecentes. Tais condutas apontam, destarte, que o Réu iria utilizar a maconha apreendida para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, inviabilizando por completo o pedido de desclassificação formulado pela Defesa para o tipo do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória, inclusive sobre a ausência de prova de atos de comércio, desnecessário diante do contexto probatório. Oportuno salientar que “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Nem se olvide pelo fato de a Acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, tanto que sequer foram

contraditados.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, "Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal e pelo artigo 42 da Lei de Drogas, é o caso de majorar sua pena-base, ponderando a considerável quantidade de maconha apreendida, assim como pelo fato de que, quando menor de idade, teve passagens pela Justiça menorista por ato infracional (fls. 31), indicativo que deve ser empregado nesta fase como critério de majoração da pena diante da personalidade do agente, porque, mesmo atingindo a maioridade penal há pouco tempo evidencia persistência na prática de condutas antissociais, verbis: "Embora o registro de ato infracional não possa ser utilizado para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do recorrente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. Precedentes." (STJ, 5ª Turma, HC 466.866/PE, j. 02.10.2018). Sendo assim, majoro sua pena-base em 1/6 (um sexto) e a fixo inicialmente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, à míngua de comprovação de suas condições financeiras.

O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, sendo ele conhecido pela traficância e por guardar considerável quantidade e diversidade de entorpecente, vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas, o que se reforça tendo em vista que ele recentemente atingiu a maioridade penal e, antes disso, praticou atos infracionais, indicativo claro que não praticou o crime ao qual ora condenado de forma esporádica, agindo de modo repentino e incontrolável, mas um verdadeiro meio de trabalho ilícito.

Nesse diapasão: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'. Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia,

estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder.

Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, é o inicial fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Públ., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos subjetivo e objetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes

hediondos e equiparados.

Relevo, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um “pequeno” traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito (sendo que o Réu não ostenta nenhum destes predicados) servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada que é ao crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: “Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações. Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou

substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, com redação dada pela Lei 11.719, de 20.06.2008, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fulcro nos artigos 62 e 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda do dinheiro apreendido (fls. 54) e do telefone celular, em favor da União.

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência CONDENO o Réu LEONARDO DOS SANTOS ALTÃO, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu menor valor, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis. No mais, decreto a perda do celular e do dinheiro apreendidos com ele, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como encaminhe-se o numerário apreendido e o celular em benefício da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado e considerando a hediondez do tráfico de entorpecentes, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, motivo porque mantenho sua prisão cautelar, sem prejuízo do conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nada justificando que, depois de condenado a um crime equiparado ao hediondo, e tendo aguardado preso seu julgamento, fosse colocado em liberdade, ficando indeferido o pedido defensivo.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA